

1500117-75.2022.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. USO DE DROGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. BUSCA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO FRANQUEADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500117-75.2022.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500117-75.2022.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2097864/2022 - DEL.SEC.BOTUCATU, 24196715 - DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS HENRIQUE MOURA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

MATEUS HENRIQUE MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 08 de abril de 2022, por volta das 20h30min., na Avenida Milton Aparecido de Oliveira, defronte ao numeral 280, Chácaras Reunidas Vista Alegre, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiras pessoas, 37 (trinta e sete) porções de cocaína, com peso líquido de 3,28g (três gramas e vinte e oito centigramas), e 91 (noventa e um) porções de cocaína em forma de "crack", com peso líquido de 24,88g (vinte e quatro gramas e oitenta e oito centigramas), drogas estas que determinam dependência física ou psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19, laudo de constatação provisória de fls. 22/26 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 77/79, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento rotineiro pelo

local dos fatos, quando avistaram o denunciado em atitudes suspeitas. Ao notar a aproximação da viatura, tentou empreender fuga, porém fora abordado.

Durante a fuga o denunciado dispensou uma sacola. Na sacola dispensada foram encontradas 91 (noventa e um) porções de "crack", 37 (trinta e sete) porções de cocaína e a quantia de R\$ 87,00 (oitenta e sete reais).

O rito da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida em 10/05/22 (fls. 90/91), o réu foi citado (fls. 138) e apresentou resposta à acusação (fls. 133/135). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 139/140) e designada audiência de instrução. Em audiência foram ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e o réu interrogado.

O Ministério Público, por meio de alegações finais (fls. 166/170) requereu a procedência da ação penal.

A defesa do réu, em sede de alegações finais (fls. 174/186), preliminarmente requereu a nulidade da apreensão realizada pelos guardas municipais, no mérito pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a infração penal disposta no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

De início, afasto a preliminar de nulidade da prova decorrente da revista pessoal realizada pela guarda municipal, pois, conforme se depreende dos autos a droga apreendida, pertencente ao acusado, foi dispensada por ele em uma sacola ao empreender fuga dos guardas municipais, não tendo sido obtida por meio de revista. Conforme relatado, em revista pessoal, nada foi encontrado com o acusado.

Apesar disso, convém frisar que sendo a revista pessoal precedida de justa causa, não há que se falar em nulidade. Se existem suspeitas fundadas em relação ao acusado estar realizando traficância, presente justa causa para justificar a busca pessoal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. USO DE DROGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. BUSCA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO FRANQUEADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO IMPROVIDO. 1. Considera-se lícita a revista pessoal executada por guardas municipais, com a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Configurada a situação de flagrância, com a demonstração de fundada suspeita, não se verifica ilegalidade na realização de abordagem pessoal por guardas municipais que estavam em patrulhamento com cães farejadores, encontrando drogas com o paciente e nas proximidades do local do flagrante, pois o acusado informou que estava usando drogas no momento em que foi abordado. 3. A questão referente à aplicação da minorante, a matéria já foi analisada no HC 563.700/SP, tratando-se de mera reiteração de pedido. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 597.923/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Ante a acurada análise dos autos, tem-se que procede a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, vez que a materialidade dos delitos veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19), pelo laudo de constatação (fls. 22/26), exame químico toxicológico (fls. 77/79), comprovante de depósito judicial do numerário apreendido em poder do réu (fls. 80) e prova oral colhida.

A autoria em relação ao tráfico de drogas está, igualmente, caracterizada.

A testemunha arrolada pela acusação Johnny Gledson Maia Silva, guarda civil municipal, relatou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando viram o réu entregando algo para terceira pessoa. Quando ambos viram a viatura, correram em sentidos opostos. Matheus tinha uma sacola nas mãos e adentrou em um terreno

baldio. Conseguiram fazer a abordagem de Matheus na Rua Waldemar Vizotto. Ao retornarem ao local encontraram a sacola, com diversas notas de dinheiro ao lado. Dentro da sacola havia 37 tubos de eppendorf de cocaína e 91 pedras de crack embaladas, prontas para venda. O acusado confessou que estava praticando tráfico de drogas, embora nada de ilícito tenha sido encontrado em revista pessoal. Foi realizada a prisão em flagrante. Viu claramente o réu dispensar a sacola enquanto tentava se evadir, o dinheiro estava fora da sacola, mas não viu o réu dispensar as notas. O local é conhecido como ponto de tráfico e já o conhecia de outras oportunidades, nesse mesmo local e nas imediações. Não conseguiu identificar a outra pessoa. Não sabe se o réu é usuário de crack. O abordou a aproximadamente 150 metros do local onde ele teria dispensado a sacola. Ele foi avistado não na rua em que fica a assim conhecida "casa da morte", mas na rua que fica atrás.

A testemunha arrolada pela acusação Shirlei Franciele Chaves, guarda civil municipal, corroborou o depoimento da testemunha GCM Johnny, acrescentando que havia R\$ 87,00 em espécie ao lado da sacola.

A testemunha arrolada pela defesa Letícia Ariane Moura Baptista Ramos, informou ser irmã do réu. Disse que não acompanhou a prisão de Matheus. Relatou que ele é usuário de drogas.

O réu, em sede policial, negou os fatos a si imputados. Em juízo, sustentando versão semelhante, refutou a imputação que sobre ele recaí. Relatou que estava na "casa da morte", uma biqueira, e tinha fumado crack. Estava indo embora quando viu a viatura, e foi abordado pela GCM Shirlei. Havia outra pessoa no local, a qual se evadiu, mas ele não correu. Um casal estava sendo abordado no mesmo momento. Os GCMs entraram na casa e voltaram de lá com drogas, dizendo que lhe pertenciam, que a pessoa que estava na casa havia dito que a droga era dele, o que ele negou. Não soube informar onde encontraram a droga, voltaram com uma sacola. É usuário há 5 anos.

Em que pese a negativa do réu, alegando que estaria no local conhecido como "casa da morte" apenas usando drogas, a mesma não convence, mostrando-se isolada nos autos. O relato das testemunhas, sob a égide do contraditório e ampla defesa, prestados com detalhes e de forma harmoniosa, são bastante convincentes e indicam a ocorrência da apreensão da droga e traficância descritas na denúncia.

A testemunha da defesa em nada acrescentou a versão trazida aos autos pelo acusado, tendo em vista que não esteve presente na data dos fatos. Trouxe em audiência nada mais do que suas opiniões pessoais acerca da personalidade do acusado.

No tocante à finalidade com que o réu guardava as substâncias entorpecentes, tendo em vista que as drogas estavam acondicionadas da forma como costumam ser embaladas para o comércio, conforme o laudo pericial, fica claro o objetivo de mercancia.

Nesse sentido:

"Tóxico - Tráfico - Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado - Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio - Desclassificação para uso inadmissível." (TJSP - AC 234.718-3 - Rel. Walter Guilherme - j. 17.02.1998 - JTJ 208/273)

As testemunhas informaram que realizaram a abordagem do acusado pois teriam o visualizado repassando algo a uma terceira pessoa, em local conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes. Contudo, importante destacar que a ausência de visualização de atos de mercancia não afasta a ocorrência do tráfico, pois a simples ação de guardar e ter em depósito os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

Apelação- Tráfico de drogas- Condenação- Recurso defensivo -Pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal- Não acolhimento- Materialidade e autoria comprovadas -Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade- Prova oral harmônica e coesa- Apelante que transportava droga pernicioso (cocaína), em quantidade elevada (25,6 gramas de massa líquida -suficientes para produzir cerca

de 100 porções individuais) e acondicionada em embalagem típica de mercancia- Circunstâncias da prisão que reforçam o "animus" de traficância- Tentativa de fuga do agente ao perceber a presença da viatura- Versão do sentenciado inverossímil e dissociada das provas coligidas- Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia -Crime de ação múltipla ou conteúdo variado- Bastante comum a figura do "traficante-usuário" ou "usuário-traficante"- Pedido de aplicação da pena no mínimo legal- Acolhimento parcial- Desproporcional a exasperação da pena-base na fração de 2/5, a despeito da quantidade de droga -Redução para 1/6- Parecer favorável da douta Procuradoria de Justiça- Na segunda fase da dosimetria, o incremento em 1/3 teve fundamento idôneo -Reincidência específica- Precedentes- Revisadas as penas definitivas- Manutenção do regime inicial fechado- Recurso parcialmente provido (TJSP - Apelação Criminal 1500148-22.2018.8.26.0578, Relator(a): Juscelino Batista, Comarca: Ourinhos, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 09/03/2021, Data de publicação:09/03/2021).

Soma-se, ainda, o fato de que a alegada condição de usuário, por si só, não impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.RECURSO DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para uso pessoal. Descabimento. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusado guardava e tinha em depósito, para fins de traficância, 44 porções de cocaína em forma de "crack", com peso de 8,38g. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do caso, afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida(TJSP - Apelação Criminal nº 1500031-25.2019.8.26.0407; Relator(a):Alcides Malossi Junio; Comarca: Osvaldo Cruz; \Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/08/2020; Data de publicação: 31/08/2020).

Como já analisado, a quantidade de drogas é expressiva, especialmente em se considerando a natureza e variedade das drogas: maconha, "crack" e cocaína". Some-se a isso a forma de acondicionamento dos entorpecentes em porções individuais, de forma própria para a venda e a apreensão dessas drogas em poder do réu em local que é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, resta claro o objetivo de mercância. Cumpre ainda destacar que também houve apreensão, no mesmo contexto fático, de certa quantia em dinheiro em poder do réu (R\$ 87,00), não sendo comprovada sua origem.

Com efeito, diante de todo o conjunto probatório, suficiente concluir que a droga descrita na denúncia pertencia ao réu e era, sem sombra de dúvida, destinada à traficância. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois nada impede que o traficante seja, ao mesmo tempo, usuário dos entorpecentes.

Demonstrada a ocorrência do crime de tráfico de drogas e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da denúncia é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Atendendo aos critérios norteadores dos artigos 42, da Lei 11.343/06 e 59, do Código Penal, em primeira fase de fixação da pena, tendo em vista a quantidade de drogas e a variedade (cocaína e "crack") e o fato de o réu ser portador de maus antecedentes (fls. 100/101), fixo a pena base acima do mínimo legal, aumentando-a em 1/3, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Em segunda fase, não verifico a presença de agravantes ou atenuantes.

Em terceira fase, não verifico a presença de causa de aumento ou diminuição de pena.

Em relação ao benefício previsto no artigo 33, 4º, da lei 11.343/06, caso seja o

réu reincidente, tenha maus antecedentes, dedique-se a atividades criminosas ou integre organização criminosa, em hipótese alguma fará jus à redução da sua pena. Mas, sendo primário, tendo bons antecedentes, e não se dedicando a atividades criminosas, nem sendo integrante de organização criminosa, poderá ou não fazer jus à redução da sua pena de um sexto a dois terços, conforme as circunstâncias do caso concreto. Aqui, entendo que o julgador deve socorrer-se, ainda, dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal e das peculiaridades do caso concreto, quer para verificar a viabilidade da aplicação do redutor da pena, quer para aplicar a redução mais adequada à hipótese.

Assim, é imprescindível, para a perfeita individualização das penas, e para evitar-se a eterna banalização das penas mínimas, que certamente não corresponde ao intuito do legislador nem aos anseios sociais, menos ainda à justa aplicação da lei ao caso concreto, analisar criteriosamente, além das condições previstas no parágrafo 4º do artigo 33, também as circunstâncias e consequências do crime, a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente, e os motivos que o levaram à prática da infração.

No caso dos autos, não há uma hipótese de extrema excepcionalidade a autorizar a redução diante da natureza e quantidade de droga encontrada com o acusado. Dessa forma, na terceira fase, justifico a ausência de aplicação da redução de pena nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista a natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

Sobre a pertinência da fixação de referido regime de cumprimento de pena, trago o seguinte precedente:

"Por fim, mantenho o regime inicial fechado para início do desconto da corporal, sendo o único compatível com o delito, dada a determinação legal em se tratando de crime hediondo (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Cumpre observar que o ilícito do qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado permitirá aos réus uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, AP 0002479-41.2010, Rel. Edison Brandão, j. 02/07/2013).

Como se sabe, a finalidade da lei é proteger a saúde pública, evitando-se o dano que o uso de drogas causa à saúde e a única forma de se coibir tal prática, com sucesso, é através do combate ao narcotráfico e da não permissão de que aqueles que se veem acusados e até condenados de tais práticas sejam, desde logo, reintegrados ao convívio social, sem que percebam a gravidade de suas ações.

No mais, persistem inalteradas todas as razões já expostas por força da decisão que decretou a prisão preventiva do réu.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o acusado MATEUS HENRIQUE MOURA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 666 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, Lei 11.343/06.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a aplicação do "sursis", em razão de não estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

O réu, diante da necessidade da prisão cautelar durante todo o processo e desta condenação que a ratifica, não poderá apelar em liberdade, pois reputo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se-o na prisão em que se encontra, com as cautelas de praxe.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão, pois são instrumentos, produtos ou proveito do crime em apreço. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-

se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.
Honorários proporcionais.
Custas na forma da lei.
P.I.C.
Botucatu, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA